

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 721/2547 บริษัทสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง จำกัด โจทก์
ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ กับพวก จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 142, มาตรา 172

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 50, มาตรา 51, มาตรา 52

พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ มาตรา 50 บัญญัติว่า ให้มีคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ และมาตรา 51 (1) บัญญัติว่า ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอำนาจ
หน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ส่วนมาตรา 52 วรรคสี่
บัญญัติว่า ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสนอคดีต่อศาลภายใน 30
วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ดังนั้น เมื่อจำเลยที่ 3 ถึงที่ 11 ซึ่งเป็น
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้พิจารณาอุทธรณ์ของโจทก์แล้วมีคำวินิจฉัยยก
อุทธรณ์ของโจทก์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ เมื่อโจทก์ไม่เห็นด้วย
โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 3 ถึงที่ 11 ได้

คำสั่งที่โจทก์ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนนั้น แม้จะลงนามโดยจำเลยที่
2 ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการโยธา แต่ก็เป็นการลงนามในฐานะเป็นผู้ได้
รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ดังนั้น ผู้ที่โต้แย้งสิทธิของโจทก์โดยตรงคือ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
จำเลยที่ 1 หาใช่จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนไม่ ทั้งกรณีไม่ใช้การฟ้องให้
จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบส่วนตัว โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2

แม้โจทก์จะฟ้องคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขอให้เพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตตามคำขออนุญาตดัดแปลงอาคารก็ตาม แต่ตามคำฟ้องไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้บรรยายฟ้องว่าโจทก์มีสิทธิโดยชอบที่จะดัดแปลงอาคารพิพาทของโจทก์ชั้นที่ 5 ซึ่งเดิมใช้เป็นที่จอดรถยนต์ให้เป็นโรงมหรสพ ตามคำขออนุญาตดัดแปลงอาคารที่ยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น แต่กลับบรรยายฟ้องยืนยันว่าคำขอดังกล่าวเป็นคำขออนุญาตดัดแปลงอาคารพิพาทระหว่างชั้นที่ 6 และที่ 7 ซึ่งไม่ตรงกับข้อความที่ระบุในคำขออนุญาตดัดแปลงอาคาร เท่ากับโจทก์ไม่ได้บรรยายฟ้องว่าจำเลยที่ 1 และที่ 3 ถึงที่ 11 ได้แย้งสิทธิของโจทก์ในการขออนุญาตดัดแปลงอาคารพิพาทที่บริเวณชั้น 5 แม้โจทก์จะแนบสำเนาคำขออนุญาตดัดแปลงอาคารมาท้ายฟ้องก็ไม่ใช่ประโยชน์แก่คดีของโจทก์ เพราะตามคำฟ้องไม่มีประเด็นให้วินิจฉัยเกี่ยวกับการดัดแปลงอาคารพิพาทที่บริเวณชั้น 5 ว่าเข้าข่ายยกเว้นข้อ 49 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 33ฯ หรือไม่ ศาลไม่อาจพิพากษาบังคับคดีให้เป็นไปตามคำขอท้ายฟ้องของโจทก์ได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด โจทก์ได้มอบอำนาจให้นายไพโรจน์ โรจนเกียรติ ฟ้องคดีนี้ โจทก์ในฐานะผู้ประกอบการค้าได้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 12 ชั้น (มีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น) จำนวน 1 หลังบนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 31484 ถึง 31488, 3985, 33089, 30217, 883, 12725 ถึง 12728, 33485 และ 3984 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และโจทก์ได้รับใบอนุญาตซึ่งใช้ได้นับตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2533 จนถึงวันที่ 7 กันยายน 2534 ต่อมาวันที่ 29 ธันวาคม

2535 โจทก์ได้ยื่นคำขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างภายในอาคารชั้นที่ 6 เพื่อให้เกิดความเหมาะสมโดยจัดเป็นที่จอดรถยนต์ให้มากขึ้นซึ่งไม่มีผลต่อโครงสร้างไม่เพิ่มจำนวนชั้น ไม่เพิ่มความสูง ไม่กระทบภายนอกอาคาร ครึ่งปลายเดือนเมษายน 2536 โจทก์ได้รับคำสั่งจากจำเลยที่ 2 ในฐานะผู้อำนวยการสำนักการโยธาปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเจ้าพนักงานท้องถิ่น จำเลยที่ 1 ตามคำสั่งเลขที่ กท 4000/453 ลงวันที่ 23 เมษายน 2536 แจ้งว่าแบบแปลนที่โจทก์ยื่นขออนุญาตแสดงส่วนที่ขออนุญาตดัดแปลงไม่ครบถ้วน ขัดต่อกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528) จัดที่จอดรถยนต์ไม่ถูกต้องตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) (ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2479) และแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาตดัดแปลงระหว่างชั้นที่ 6 และชั้นที่ 7 ถือว่าเป็นการดัดแปลงโดยการเพิ่มขึ้น จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ซึ่งเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2536 โจทก์ได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ระหว่างอุทธรณ์ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร กรมโยธาธิการ มีหนังสือด่วนมาก ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2538 แจ้งให้โจทก์ไปชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เพื่อประกอบคำวินิจฉัย ต่อมาวันที่ 2 กันยายน 2538 โจทก์ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์ตามหนังสือที่ มท 0818/1096 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2538 ซึ่งโจทก์ไม่เห็นพ้องด้วย เพราะไม่เปิดโอกาสให้โจทก์ได้รับทราบถึงเหตุผลและข้อบกพร่องเพื่อดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับในกฎหมายกระทรวง คำสั่งที่ว่าโจทก์จัดที่จอดรถยนต์ไม่ถูกต้องตามกฎหมายกระทรวงและแบบแปลนที่ขออนุญาต ดัดแปลงระหว่างชั้นที่ 6 และชั้นที่ 7 ถือเป็นการดัดแปลง การดัดแปลงเพิ่มขึ้นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) นั้น ที่จริงแล้วชั้นที่ 7 ตามแบบคำขออนุญาตไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด นอกจากนี้ ตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ข้อ 49 ได้บัญญัติไว้ว่าการก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่ได้ยื่น

คำขออนุญาตหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารไว้แล้วก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ เมื่อใบอนุญาตก่อสร้างอาคารพิพาทได้ออกให้แก่โจทก์ก่อนวันที่กฎกระทรวงฉบับนี้ใช้บังคับ โจทก์จึงสามารถดำเนินการดัดแปลงอาคารได้ สำหรับหนังสือขอเชิญประชุมนั้นไปถึงโจทก์ก่อนวันประชุมเพียง 1 วัน โดยพิมพ์วันนัดหมายคลาดเคลื่อน ทำให้โจทก์ไม่สามารถไปชี้แจงได้ คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คลาดเคลื่อนต่อคำสั่งที่ออกและพยานหลักฐานที่โจทก์ได้ยื่นไว้แล้วและคลาดเคลื่อนต่อมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 โจทก์ไม่ได้ดำเนินการดัดแปลงตามความหมายของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในชั้นที่ 6 เพราะไม่ได้เพิ่มความสูง ไม่เพิ่มขนาด ไม่กระทบต่อภายนอกอาคารและไม่กระทบต่อโครงสร้าง เป็นการจัดสรรประโยชน์ใช้สอยในพื้นที่เพื่อเพิ่มที่จอดรถยนต์ให้สูงสุดเท่านั้น ขอให้เพิกถอนคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ออกโดยจำเลยที่ 1 และที่ 2 เลขที่ กท 4000/453 ลงวันที่ 23 เมษายน 2536 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (ที่ 636 - 38/2538) ที่ออกโดยจำเลยที่ 3 ถึงที่ 11 ซึ่งแจ้งให้โจทก์ทราบตามหนังสือที่ มท 0818/1096 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2538 กับให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้มีอำนาจรับผิดชอบตามกฎหมายออกใบอนุญาตตามคำขอแก่โจทก์ตามคำขอเลขรับที่ 1151/2535 และ 1152/2535 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2535

จำเลยทั้งสิบเอ็ดให้การ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า โจทก์ไม่น่าสืบว่าจำเลยที่ 3 ถึงที่ 11 ได้แย้งสิทธิของโจทก์ จึงฟังได้ว่าจำเลยที่ 3 ถึงที่ 11 ไม่ได้โต้แย้งสิทธิของโจทก์ การที่จำเลยมีคำสั่งให้โจทก์แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังตามคำสั่งเลขที่ กท 4000/453 เป็นคำสั่งที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมาย และตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 51 ให้อำนาจคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีหนังสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำ

หรือให้ส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา แม้จะฟังว่ามีการกำหนดวันนัดประชุมผิดพลาดทำให้โจทก์ไม่มีโอกาสชี้แจง ก็ไม่ทำให้คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไม่ชอบ การที่โจทก์ก่อสร้างเพิ่มขึ้นระหว่างชั้นที่ 6 และชั้นที่ 7 ถือว่าเป็นการต่อเติมเพิ่มส่วนต่าง ๆ ของอาคารซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วให้ผิดไปจากเดิม หาใช่เป็นการซ่อมแซมหรือดัดแปลงดังที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงแต่อย่างใดไม่ และเมื่อกระทำขึ้นภายหลังกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ใช้บังคับแล้ว กรณีต้องขออนุญาตดัดแปลงเสียก่อน ดังนั้น การที่โจทก์ดัดแปลงโดยมิได้รับอนุญาต จึงเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประเด็นข้ออื่นไม่จำต้องวินิจฉัย พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งแจ้งโจทก์ (ตามคำสั่งเลขที่ กท 4000/453 เอกสารหมาย จ.10) ว่า แบบแปลนและรายการที่โจทก์เสนอ ประกอบคำขออนุญาตดัดแปลงอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายเกณฑ์ต่าง ๆ โดยยังไม่ถึงกับไม่อนุญาตให้โจทก์ดัดแปลงอาคารเสียทีเดียว เป็นการชอบด้วยเหตุผลและระเบียบปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องแล้ว กรณีไม่จำเป็นต้องพิจารณาว่าโครงสร้างอาคารเดิมสามารถรับน้ำหนักอาคารส่วนที่ดัดแปลงใหม่ได้หรือไม่ เพราะไม่ใช่ประเด็นแห่งคดี การที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์เป็นคำวินิจฉัยที่ ชอบแล้ว โดยไม่จำเป็นต้องให้โจทก์เข้าชี้แจงประกอบอุทธรณ์ เมื่อโจทก์ดำเนินการขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามคำขอเลขรับที่ 1151/2535 และ 1152/2535 ไม่ครบถ้วนถูกต้องจึงไม่อาจบังคับให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้โจทก์ดัดแปลงอาคารตามคำขอได้ คดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยประเด็นข้ออื่นอีก พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาคณะคดีปกครองวินิจฉัยว่า "...มีปัญหาข้อกฎหมายต้องวินิจฉัยตาม ฎีกาของโจทก์และคำแก้ฎีกาของจำเลยที่ 3 ถึงที่ 11 เป็นข้อแรกว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 3 ถึงที่ 11 หรือไม่ ในปัญหาข้อนี้ จำเลยที่ 3 ถึงที่ 11 อ้างว่า จำเลยที่ 3 ถึงที่ 11 มิใช่เจ้าพนักงานท้องถิ่น แม้จำเลยที่ 3 ถึงที่ 11 จะเป็นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และมีคำสั่งยกอุทธรณ์ของโจทก์ โดยยื่นตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ไม่อนุญาตให้โจทก์ดัดแปลงอาคารพิพาท สิทธิของโจทก์ก็ถูกโต้แย้งโดยคำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นมูลฐาน มิได้ถูกโต้แย้งโดยคำวินิจฉัยของจำเลยที่ 3 ถึงที่ 11 แต่อย่างไร โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 3 ถึงที่ 11 เป็นคดีนี้ เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 50 ได้บัญญัติว่า ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และมาตรา 51 (1) บัญญัติว่า ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ส่วน มาตรา 52 วรรคสี่ บัญญัติว่า ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสนอคดีต่อศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ดังนั้น เมื่อจำเลยที่ 3 ถึงที่ 11 ซึ่งเป็นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้พิจารณาอุทธรณ์ของโจทก์แล้วมีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ เมื่อโจทก์ไม่เห็นด้วย โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 3 ถึงที่ 11 ซึ่งเป็นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต่อศาลได้ตามบทกฎหมายดังกล่าว ฎีกาข้อนี้ของโจทก์ฟังขึ้น ส่วนคำแก้ฎีกาของจำเลยที่ 3 ถึงที่ 11 ฟังไม่ขึ้น

สำหรับคดีโจทก์ในส่วนของจำเลยที่ 1 และที่ 2 นั้น ศาลฎีกาคณะคดีปกครองเห็นสมควรวินิจฉัยเสียก่อนว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2 ด้วยหรือไม่ เห็นว่า คำสั่งเลขที่ กท 4000/453 ลงวันที่ 23 เมษายน 2536 เอกสารหมาย จ.20 ที่โจทก์ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนนั้น แม้จะลงนามโดยจำเลยที่ 2 ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการโยธา แต่ก็เป็นการลงนามในฐานะเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงต้อง

ถือว่าผู้ที่มีคำสั่งดังกล่าวคือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ดังนั้น ผู้ที่ได้แย้งสิทธิของโจทก์โดยตรงคือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจำเลยที่ 1
หาใช่จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนจำเลยที่ 1 ไม่ ทั้งกรณีนี้ก็ไม่ใช่การฟ้อง
ให้จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบส่วนตัว โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2 เป็นคดีนี้ได้
และเมื่อมีการแจ้งคำสั่งเลขที่ กท 4000/453 ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเจ้า
พนักงานท้องถิ่นไปยังโจทก์นั้น โจทก์ผู้ได้รับคำสั่งหากไม่เห็นด้วยก็ต้องอุทธรณ์
คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 52 วรรคหนึ่ง โจทก์ได้รับแจ้ง
คำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2536 ตามใบตอบรับในชุดเอกสารหมายเลข จ.10
แต่โจทก์เพิ่งทำหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวไว้ในข้ออุทธรณ์ประเด็นแรกตาม
อุทธรณ์เอกสารหมายเลข จ.11 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2536 และนำไปยื่นต่อกอง
ควบคุมอาคาร สำนักการโยธา เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2536 จึงพ้นกำหนดเวลาที่
โจทก์จะยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวได้ เมื่อโจทก์ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมาย
บัญญัติไว้ โจทก์จะฟ้องจำเลยที่ 1 เพื่อขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่
1 ตามคำสั่งเลขที่ กท 4000/453 ดังกล่าวหาได้ไม่ ปัญหาดังกล่าวมานี้เป็นข้อ
กฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จะไม่มีคู่ความฝ่ายใดยก
ขึ้นฎีกา ศาลฎีกาคณะคดีปกครองก็มีอำนาจยกปัญหานี้ขึ้นวินิจฉัยแล้วพิพากษาคดี
ไปได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 (5) ประกอบด้วย
มาตรา 246 และ 247

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ข้อต่อไปว่า คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่ให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์เป็นคำวินิจฉัยที่ชอบหรือไม่ เห็น
ว่า ตามอุทธรณ์ของโจทก์ที่ยื่นต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามเอกสารหมายเลข
จ.11 นั้น โจทก์ได้ตั้งประเด็นไว้ในอุทธรณ์ 2 ข้อ โดยประเด็นข้อแรกโจทก์อุทธรณ์
ว่า อาคารพิพาทของโจทก์ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 33

(พ.ศ.2535) มีผลใช้บังคับ อาคารพิพาทของโจทก์จึงเข้าข้อยกเว้นข้อที่ 49 ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับนี้ การที่จำเลยที่ 1 เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกคำสั่งให้โจทก์แก้ไขแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาตดัดแปลงระหว่างชั้นที่ 6 และชั้นที่ 7 ตามข้อ 1.3 (ของคำสั่งเลขที่ กท 4000/453) ย่อมเป็นการไม่ถูกต้อง เพราะตามข้อเท็จจริงแล้วส่วนที่ต่อเติมระหว่างชั้นที่ 6 และชั้นที่ 7 ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือข้อบัญญัติอื่น ๆ แต่ประการใด และเป็นการดัดแปลงเฉพาะภายในอาคารเท่านั้น มิได้มีส่วนหนึ่งส่วนใดทำให้อาคารเพิ่มขนาดความสูงหรือเพิ่มขนาดความกว้างยาวออกไปนอกอาคารแต่อย่างใด ขอให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยชี้หาความเป็นธรรมแก่โจทก์ด้วย ส่วนประเด็นข้อสองโจทก์อุทธรณ์ว่า ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีความเห็นว่า โจทก์ดัดแปลงอาคารขัดต่อกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) จำเลยที่ 1 ก็ยังใช้อำนาจหน้าที่ไม่ถูกต้องอยู่ดี เนื่องจากโจทก์ได้มีหนังสือแจ้งให้จำเลยที่ 1 ทราบว่าการนับชั้นไม่ตรงกับการนับชั้นของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ก็มีได้ยกเหตุดังกล่าวมาพิจารณาและมิได้แจ้งให้โจทก์ทราบข้อบกพร่องแต่อย่างใด กลับใช้อำนาจหน้าที่สั่งไม่อนุญาตให้โจทก์ดัดแปลงอาคารตามคำสั่งเลขที่ กท 4000/1335 ขอให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ยกเลิกคำสั่งไม่อนุญาตให้ดัดแปลงอาคารของจำเลยที่ 1 ดังนี้ จึงเห็นได้ว่า ประเด็นข้อแรกโจทก์โต้แย้งคำสั่งของจำเลยที่ 1 ที่สั่งให้โจทก์แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนตามข้อ 1.3 ของเอกสารหมาย จ.10 ซึ่งจำเลยที่ 1 ระบุไว้ว่าแบบแปลนที่โจทก์ยื่นขออนุญาตดัดแปลงระหว่างชั้นที่ 6 และชั้นที่ 7 ถือเป็นการดัดแปลงโดยการเพิ่มชั้น จะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) แต่แบบแปลนที่โจทก์ยื่นไว้ยังไม่ถูกต้อง ในปัญหาข้อนี้จำเลยที่ 3 ถึงที่ 11 ซึ่งเป็นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยว่า สำหรับประเด็นการดัดแปลงอาคารของโจทก์ระหว่างชั้นที่ 6 และชั้นที่ 7 เพื่อใช้เป็นที่พักจอดรถยนต์นั้น จากข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคารในส่วนนี้ จึงไม่จำเป็นต้องพิจารณาในส่วนนี้ ศาลฎีกาคณะคดีปกครองเห็นว่า เป็นคำวินิจฉัยที่ชอบด้วยเหตุผล

แล้ว เพราะตามทางพิจารณาโจทก์ได้ยื่นคำขออนุญาตจัดแปลงอาคารเลขรับที่ 1151/2535 และ 1152/2535 ขออนุญาตจัดแปลงอาคารชั้นที่ 5 เป็นโรงแรมรสป จำนวน 4 โรงเท่านั้น โดยไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้ยื่นคำขออนุญาตจัดแปลงอาคาร ระหว่างชั้นที่ 6 และชั้นที่ 7 เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยด้วยแต่อย่างใด กรณีจึงไม่จำ ต้องวินิจฉัยว่าการจัดแปลงอาคารของโจทก์ที่บริเวณระหว่างชั้นที่ 6 และชั้นที่ 7 ตามฟ้องเข้าข้อยกเว้นข้อ 49 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) หรือไม่อีก ส่วนที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยว่าอาคารพิพาทของโจทก์มีความสูง 53.10 เมตร เข้าข่ายเป็นอาคารสูงตามกฎหมาย ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ซึ่งมีผล ใช้บังคับเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2535 ต่อมาวันที่ 29 ธันวาคม 2535 โจทก์ได้ยื่น คำขออนุญาตจัดแปลงอาคารดังกล่าวที่บริเวณชั้นที่ 5 เพื่อใช้เป็นโรงแรมรสป ภาย หลังจากที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ใช้บังคับ ซึ่งกฎกระทรวงฉบับดัง กล่าวข้อ 3 กำหนดว่า อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องมีถนนหรือที่ว่าง ปราศจากสิ่งปกคลุมโดยรอบอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร แต่จากข้อเท็จจริง ปรากฏว่า อาคารของโจทก์มีที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมด้านทิศตะวันออก ด้านทิศ ใต้และด้านทิศตะวันตกมีความกว้างน้อยกว่า 6 เมตร ดังนั้น การจัดแปลงอาคารของ โจทก์ที่บริเวณชั้นที่ 5 จึงไม่สามารถกระทำได้นี้เนื่องจากขัดต่อกฎกระทรวงฉบับดัง กล่าว และไม่ได้รับการยกเว้นตามข้อ 49 ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว ดังนั้น การ ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อนุญาตให้โจทก์จัดแปลงอาคารจึงเป็นการถูกต้องแล้วนั้น เห็นว่า แม้คดีนี้โจทก์จะฟ้องคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขอให้เพิกถอนคำสั่งของ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และขอ ให้ศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น (จำเลยที่ 1) ออกใบอนุญาตตามคำขอ อนุญาตจัดแปลงอาคารเลขรับที่ 1151/2535 และ 1152/2535 ก็ตาม แต่ตามคำ บรรยายฟ้องของโจทก์ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้บรรยายฟ้องว่าโจทก์มีสิทธิโดยชอบที่จะ จัดแปลงอาคารพิพาทของโจทก์ชั้นที่ 5 ซึ่งเดิมเป็นที่จอดรถยนต์ให้เป็นโรงแรมรสป

จำนวน 4 โรง ตามคำขออนุญาตดัดแปลงอาคารดังกล่าวแต่อย่างใด โจทก์กลับบรรยายฟ้องยืนยันว่าคำขออนุญาตดัดแปลงอาคารดังกล่าวเป็นคำขออนุญาตดัดแปลงอาคารพิพาทระหว่างชั้นที่ 6 และชั้นที่ 7 เพื่อใช้เป็นที่ยอดรถยนต์เพิ่มขึ้นซึ่งไม่ตรงกับข้อความที่ระบุในคำขออนุญาตดัดแปลงอาคารทั้งสองฉบับดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ ตามคำฟ้องของโจทก์เท่ากับว่าโจทก์ไม่ได้บรรยายฟ้องว่าจำเลยที่ 1 และที่ 3 ถึงที่ 11 ได้โต้แย้งสิทธิของโจทก์ในการขออนุญาตดัดแปลงอาคารพิพาทที่บริเวณชั้นที่ 5 ซึ่งเดิมเป็นที่ยอดรถยนต์ให้เป็นโรงมหรสพจำนวน 4 โรง แม้โจทก์จะแนบสำเนาคำขออนุญาตดัดแปลงอาคารเลขรับที่ 1151/2535 และ 1152/2535 มาทนายฟ้อง ก็ไม่เป็นประโยชน์แก่คดีโจทก์ เพราะตามคำฟ้องไม่มีประเด็นให้ต้องวินิจฉัยเกี่ยวกับการดัดแปลงอาคารพิพาทชั้นที่ 5 ให้เป็นโรงมหรสพจำนวน 4 โรงว่าเข้าข้อยกเว้นในข้อ 49 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) หรือไม่ ศาลฎีกาคณะคดีปกครองจึงไม่อาจพิพากษาลงบังคับคดีให้เป็นไปตามคำขอทนายฟ้องของโจทก์ได้ เมื่อวินิจฉัยดังนี้แล้ว ปัญหาข้ออื่นตามฎีกาของโจทก์ จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยอีกต่อไป เพราะไม่ว่าจะวินิจฉัยไปในทางใดก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงผลของคำพิพากษานี้ได้ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องโจทก์มานั้น ศาลฎีกาคณะคดีปกครองคงเห็นพ้องด้วยในผลฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สุรชาติ บุญศิริพันธ์-ประพันธ์ ททรัพย์แสง-กิตติศักดิ์ กิตติคุณไพโรจน์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ